

1500518-85.2022.8.26.0246

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano Correa Ortega

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... exige para a configuração do crime de tráfico a presença de elemento subjetivo especial do tipo, como o faz para o delito de posse de droga para consumo próprio. Nesse sentido, a lição de Renato Brasileiro de Lima, em seu Legislação Criminal Especial Comentada (2021, p. 1.068):

"Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

2ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500518-85.2022.8.26.0246 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500518-85.2022.8.26.0246

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225420/2022 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 26835544 -

DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2225420 - DEL.POL.ITAPURA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGATHA SILVA DE CARVALHO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Correa Ortega

Vistos.

Trata-se de processo-crime proposto pelo Ministério Público Estadual contra a Sra. Aghata Silva Carvalho. Na denúncia, narra-se que no dia 17 de agosto de 2022, às 19h40, na Rua Treze de Maio, nº 642, Cidade de Itapura/SP, Comarca de Ilha Solteira/SP, a denunciada, qualificada à fl. 45, guardava e mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 42 (quarenta e duas) porções de maconha, com peso aproximado de 160 gramas; 324 (trezentos e vinte e quatro) porções de crack, com peso total aproximado de 147 gramas; e 68 (sessenta e oito) porções de cocaína, com peso aproximado de 28 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/16, auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes de fls. 17/18 e fotos de fls.

22/30.

Auto de exibição/apreensão às fls. 14/16.

Prisão em flagrante convertida em preventiva e substituída por prisão domiciliar (fls. 52/53).

Os laudos de constatação preliminar (fls. 17/18) e definitiva tiveram resultado positivo para cocaína, crack e maconha (fls. 108/110, 114/116 e 117/119).

Notificado pessoalmente (fl. 170), o réu ofereceu defesa escrita (fl. 128).

Recebida a denúncia em 17 de outubro de 2022 (fls. 130/131).

Folha de Antecedentes Penais (fls. 143/144) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fl. 145).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

As partes apresentaram memoriais.

É o relatório.

Decido.

O crime de tráfico de drogas está previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 núcleos, tratando-se de tipo misto alternativo, ou seja, ainda que o agente pratique mais de um núcleo, a ele será imputado apenas um delito. Além disso, da leitura do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conclui-se que o crime pode restar configurado ainda que a alienação da droga se dê gratuitamente, mas desde que a conduta seja praticada sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ato contínuo de análise do tipo penal, deve-se observar que a lei não exige para a configuração do crime de tráfico a presença de elemento subjetivo especial do tipo, como o faz para o delito de posse de droga para consumo próprio. Nesse sentido, a lição de Renato Brasileiro de Lima, em sua Legislação Criminal Especial Comentada (2021, p. 1.068):

"Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que a tipificação desse crime dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (Dezoito) verbos constantes do art. 33. A propósito, ambas as Turmas Criminais do STJ têm precedentes no sentido de que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado, pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies de tipos congruentes, vez que há uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo - o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou especial fim de agir)."

No sentido que se vem de expor, veja-se o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DESCCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da

investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

As substâncias apreendidas foram identificadas pelos peritos como tetraidrocanabinol e cocaína (fls. 108/110, 114/116 e 117/119), definida como droga pelo art. 66 da Lei nº 11.343/2006 e pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

O auto de apreensão e a prova oral produzida em juízo provam que estavam na posse da ré.

Merece maior crédito a narrativa policial, desprovida de incoerências e de suspeita de interesse dos milicianos na causa (não há razão para acusarem injustamente os réus). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

Precedentes.

- A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante - quando estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como de venda de drogas, ocasião em que o paciente ao avistar a chegada da polícia, iniciou uma fuga, havendo sido detido pelos agentes, portando uma pochete contendo 19 porções de maconha, pesando 57,9 gramas e 69 eppendorfs de cocaína, pesando 19,5 gramas (e-STJ, fl. 93) -, Some-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado a mercancia aos policiais no momento da abordagem.

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente.
2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.

3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento.

5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP.

6. Ordem denegada.

(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)

Além disso, a versão conflitante da ré desamparada de qualquer outra prova e contrastante com a narrativa coerente e minuciosa dos policiais indica que a acusada se dedicava à mercancia de drogas.

Desta feita, reputo que os entorpecentes estavam na posse da parte ré, com a finalidade de traficância.

No caso, a quantidade e variedade de droga apreendida, as circunstâncias da apreensão (parte ré em local público, conhecido como ponto de venda de drogas, sem qualquer sinal de consumo de entorpecente) e a forma de acondicionamento da droga (pequenas porções prontas para a venda) demonstram que era destinada ao consumo de terceiros, e não próprio. Assim, caracterizado o crime de tráfico.

Em juízo, a testemunha comum, Sr. Bruno dos Santos Lima Rocha, policial militar, declarou que: receberam diversas denúncias em desfavor da acusada, sendo que as informações indicavam que a ré estaria promovendo tráfico de drogas. Em diligências, avistaram o Sr. Alexandre de frente a residência da acusada. O referido, ao avistar a viatura, atirou algo para dentro da residência da ré. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Alexandre. Após, avistaram a acusada arremessando algo em direção a uma residência abandonada. Solicitaram que a ré deixasse o imóvel. Em diligências, localizaram o objeto (saco plástico com entorpecentes) atirado pela ré. Indagada, a acusada chorou e declarou que estava promovendo o tráfico de drogas para sustentar sua família. Não é comum encontrar na cidade a quantidade de drogas localizada (aproximadamente 300 gramas), entretanto, em ocorrência anterior, localizaram, na residência da ré, quantidade semelhante de entorpecentes, oportunidade em que o marido da ré foi preso em flagrante. Indagado, Alexandre disse que estava no local para “resolver um negócio de cachorro”, negado a propriedade de qualquer entorpecente.

A testemunha comum, Sr. Leandro Melo dos Santos, policial militar, declarou que: havia denúncias de que a acusada estava promovendo o comércio de drogas. Relata que, em oportunidade anterior, a acusada foi presa juntamente com seu marido, por tráfico de entorpecentes. Em diligências, avistaram um homem em frente a residência da ré. O referido, ao avistar a viatura, atirou algo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o homem, porém nas proximidades localizaram dois invólucros de entorpecentes. Posteriormente, em vistorias nas proximidades, declara que avistou a acusada atirando algo para fora de seu imóvel, em um terreno.

Solicitou que a acusada deixasse o imóvel para ser averiguada. Em seguida, adentrou ao terreno, localizado no fundo da propriedade da ré. No local, encontrou uma sacola plástica com entorpecentes e dinheiro. Em relação a quantidade de drogas apreendida, declarou que não é comum apreender elevado número de invólucros na cidade. Não participou da apreensão envolvendo a ré e seu marido, ocorrida aproximadamente quinze dias antes destes fatos.

A testemunha da defesa, Sr. Alexandre Augusto Camargo Menezes, declarou que: foi à residência da ré para conversar a respeito de um cachorro que havia comprado. Declara que nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Não tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Nega qualquer envolvimento com o tráfico ou uso de drogas. Nega que tenha ido à residência para comprar drogas.

A acusada, Sra. Agatha Silva de Carvalho, declarou que: trabalha como operadora de caixa e não faz uso de entorpecente. Negou os fatos narrados na denúncia. Afirma que não leu seu depoimento prestado em sede policial, negando qualquer tipo de confissão. Argumenta que o entorpecente encontrado pertence a seu marido. Asseverou que encontrou o entorpecente no dia anterior. No dia dos fatos, ao avistar a equipe policial, sentiu “medo de ser presa” e decidiu se desfazer do entorpecente. Aduz que seu marido declarou que o entorpecente estava enterrado na residência e não foi encontrado na primeira operação realizada no imóvel. Pediu ao marido que parasse de vender entorpecentes.

Não há se falar em nulidade das provas colhidas pela entrada dos policiais na casa do réu, pois é certo que as drogas foram encontradas na posse do acusado em momento anterior, na via pública, em regular abordagem policial. Lado outro, presente a situação de flagrância, dispensados estariam os policiais de requerer mandado de busca. Seja como for, nada há nos autos a demonstrar que o réu tenha sido de qualquer modo coagido a permitir a entrada das forças de segurança pública em seu domicílio.

De mais a mais, é ponto pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido (HC 461377/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; EDcl no HC 463656/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/10/2018, DJe 24/10/2018). Por todos, veja-se o seguinte precedente do STF:

“HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Ante a envergadura maior do habeas, voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não há como deixar de adentrar-se à matéria de fundo, pouco importando que direcione à análise do cabimento e processamento de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, ainda que direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – CONSEQUÊNCIA. A irregularidade na representação processual implica a inexistência do ato de interposição, inviabilizando o conhecimento pelo Órgão judicante. COMPETÊNCIA – AFERIÇÃO – JUÍZO. A competência há de ser aferida considerado o Juízo, revelando-se impróprio cogitar de fixação em relação à pessoa do magistrado. PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA – REPERCUSSÃO – AÇÃO PENAL. Eventual ausência de justa causa para a formalização do flagrante não repercute na validade da ação penal. TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente.

PENA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.
(HC 129489, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019)"

Dispõe o art. 33, §4º, da Lei

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre a figura do tráfico privilegiado, cumpre firmar, desde já, algumas premissas, colhidas da pacífica jurisprudência dos tribunais superiores:

(i) a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes (HC 510077/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 05/08/2019; AgRg no REsp 1449194/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/09/2017, DJe 04/10/2017);

(ii) a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa (AgRg no HC 668.599/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021; AgRg no REsp 1924209/MG, Rel. Min. Feliz Fischer, Quinta Turma, j.m 13/04/2021, DJe 26/04/2021).

(iii) não é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (STF, HC 184.979-AgR/SP, Rel. Ministra CÂRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe 07/08/2020; REsp 1916596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

(iv) é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa (AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/06/2019, DJe 02/08/2019; AgRg no AREsp 1327778/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.14/05/2019, DJe 24/05/2019);

(v) diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito (HC 477280/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019; HC 458735/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/10/2018, DJe 23/10/2018);

(vi) as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (Repercussão Geral Tema 712). Assim, a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem (AgRg no HC 497047/SP, Rel. Min. Rogério SCchietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/05/2019, DJe 25/06/2019; HC 472052/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

(vii) a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF (HC 510248/SP, Rel. Ministro Joel Ilan

Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, DJe 13/06/2019; HC 491328/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.18/06/2019, DJe 01/07/2019);

(viii) reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inexistindo óbice à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (HC 482234/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/06/2019, DJe 14/06/2019; HC 482626/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/03/2019, DJe 09/04/2019); e

(ix) o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600; AgRg no HC 485746/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019, DJe 17/06/2019; AgRg no HC 485237/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

No presente caso, tem-se que a ré é tecnicamente primária e não possui maus antecedentes. No entanto, o auto de exibição e apreensão, o auto de constatação preliminar e definitivo dos entorpecentes demonstram a quantidade significativa e variedade de drogas que estava em posse da parte ré, ademais, o modo em que estavam armazenadas indica que eram utilizadas para o comércio, portanto, supõe-se que a ré se dedica a atividades ilícitas. Desta feita, afastado o redutor do tráfico de drogas privilegiado previsto no art. 33, §4º, da lei 11.343/2006. Nesse sentido, o seguinte precedente do TJSP:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL: PENA - MAJORAÇÃO - AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 - ADMISSIBILIDADE - RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES - IRRELEVÂNCIA - QUANTIDADE IMPORTANTE DE DROGAS DIVERSAS APREENDIDA - EVIDENTE ENVOLVIMENTO E DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - BENEFÍCIO AFASTADO - RECURSO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO - REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE INDICAM A INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502558-17.2020.8.26.0535; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/10/2022; Data de Registro: 06/10/2022).

Não incidem quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes.

A acusada, apesar de negar os fatos descritos na denúncia, não deu qualquer explicação plausível e convincente para os fatos retratados nos autos nem trouxe qualquer prova que pudesse confirmar e subsidiar sua versão.

As declarações da ré não demonstram coerência com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. A versão por ela apresentada não guarda correspondência com a realidade, porque a narrativa empregada é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal. Os argumentos, portanto, mostram-se inverossímeis, por não encontrar respaldo fático.

Percebe-se, enfim, no discurso, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual a versão por ele apresentada não pode ser aceita.

Para desconsideração dos relatos dos policiais, isto é, tornar suspeita a conduta ou mesmo o achado de drogas, necessário seria que houvesse rematada incoerência nos relatos, o que não sucedeu no caso dos autos. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Na espécie,

inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas, formulado pela impetrante na petição inicial do writ, porquanto tal pleito não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. 3. Com efeito, a questão objeto do presente habeas corpus não pode ser submetida diretamente a esta Corte Superior, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 4. Por outro lado, no caso concreto, o Tribunal a quo consignou: "ART. 33 DA LEI DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes." 5. A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório. 6. Habeas corpus não conhecido (HC 321.756/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015).

Não se cuida de hierarquizar o relato dos policiais que procederam à abordagem, senão de analisar globalmente tudo quanto relatado e comprovado nos autos.

Deste modo, robusto o conjunto probatório amealhado.

Tudo bem examinado e ponderado, deve ser observado, ainda nesta sede, que nada alegou a defesa que permitisse afastar a antijuridicidade da conduta delitiva imputada à parte ré, a qual, aliás, agiu com entendimento, autodeterminação e ciência da ilicitude do fato praticado, quando era certamente de se lhe exigir a adoção de conduta diversa.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que a Sra. Aghata Silva Carvalho praticou o delito de tráfico de drogas, devendo ser responsabilizada penalmente pela sua conduta.

DOSIMETRIA

Dosimetria da Pena do Crime de Tráfico de Drogas praticado pela Sra. Aghata Silva Carvalho.

Em atenção ao Princípio da Individualização das Penas (art. 5º, inc. XLVI, da CF/88) e ao Sistema Trifásico (art. 68 do CP), passo à dosimetria. (,sem descuidar do disposto no 291, §4º, do CTB.)

Na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei 11.343/06), deve ser observado que a natureza e a quantidade da substância apreendida. No mais, tem-se que:

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), tem-se que:

i) Na análise da culpabilidade, deve-se examinar, na lição de Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 788), "(...) a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu". O auto de exibição e apreensão, o auto de constatação preliminar e definitivo dos entorpecentes demonstram a quantidade significativa e variedade de drogas que estava em posse da parte ré, ademais, o modo em que estavam armazenadas indica que eram utilizadas para o comércio, portanto, supõe-se que a ré se dedica a atividades ilícitas. Assim, a culpabilidade deve ser valorada como circunstância judicial negativa.

ii) Na análise dos antecedentes, deve-se examinar a vida pregressa do réu na seara criminal. Antes, porém, de proceder a este exame, faz-se oportuno estabelecer alguns parâmetros - à luz da doutrina e da jurisprudência dominantes -, a serem observados.

Segundo Masson, em seu Código Penal Comentado (2021, p. 416), para a caracterização dos maus antecedentes, "basta a existência de uma condenação penal definitiva", sendo que o "trânsito em julgado da condenação pode ser anterior ou posterior à prática do novo delito". Assim, é suficiente que o antecedente criminal: (i) seja relativo a fato anterior à infração em julgamento (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013; STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014); e (ii) tenha se formado

definitivamente (transitado em julgado) antes do julgamento do crime em que ele é valorado.

Nesta ordem de ideias, pode ocorrer de a parte ré possuir uma ou mais condenações definitivas por fatos praticados antes do que está sendo atualmente julgado.

Cumprе, portanto, estabelecer uma casuística a este respeito.

Em havendo uma única condenação por infração penal anterior, registrada no histórico criminal da parte ré, devem-se distinguir ao menos duas situações: (i) se o trânsito em julgado da condenação pelo fato pretérito for posterior ao fato em julgamento, então estar-se-á diante de um mau antecedente; ou (ii) se tanto o fato pretérito, quanto o trânsito em julgado da condenação a ele relativa, forem anteriores ao fato em julgamento, então estar-se-á diante da reincidência em sentido técnico (art. 63 do CP), salvo se houver transcorrido o prazo depurador (art. 64, inc. I, do CP), hipótese em que a condenação definitiva anterior será valorada como antecedente criminal, observado o sistema da perpetuidade, abaixo examinado.

Em havendo duas ou mais condenações por infrações penais anteriores, registradas no histórico criminal da parte ré, pode ocorrer de: (i) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado (a) após o trânsito em julgado de uma condenação por delito anterior, caso em que essa será valorada como reincidência; e (b) após a prática de outro delito, cujo trânsito em julgado sobreveio antes do julgamento atual, caso em que essa será valorada como mau antecedente; ou (ii) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado após o trânsito em julgado de duas ou mais condenações por delitos anteriores, caso em que uma poderá ser considerada como reincidência e a outra (ou mais) como mau antecedente, observado o entendimento consagrado na Súmula 241 do STJ ("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial").

Aqui, cabe observar que, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema Repetitivo 1077, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Um resumo do quanto exposto nos é oferecido por Masson (idem, p. 444): "(...) se o réu possui mais de uma condenação definitiva, uma pode ser utilizada como mau antecedente e a outra como agravante genérica (reincidência, não se falando em bis in idem. Na hipótese de múltiplas condenações definitivas, o magistrado deve utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, se for o caso, e as demais como maus antecedentes."

Sobre o momento da condenação penal definitiva utilizada como mau antecedente, vale observar que a ela não se aplica o período depurador de que trata o art. 64, I, do CP, conforme decidido pelo STF, em sede de Repercussão Geral, RE 593.818, Tema 150. Em outras palavras, o sistema penal adota a regra da perpetuidade em matéria de antecedentes (nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: 5ª Turma, AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 15/09/2020, DJe.

21/09/2020; e 6ª Turma, AgRg no REsp 1790225/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). Portanto, é possível considerar qualquer condenação anterior (desde que já transitada em julgado e relativa a fato praticado antes daquele atualmente em julgamento), ressalvadas aquelas por atos infracionais pretéritos, pois que não configuram "crime" em sentido estrito (STJ, 5ª Turma, HC 623.117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021, DJe. 12/02/2021; e STJ, 6ª Turma, REsp 1702051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/03/2018, DJe. 14/03/2018).

Por fim, conforme pacífico entendimento do STJ, "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula 636 do STJ), o que, contudo, não afasta a possibilidade de serem eles comprovados por outros meios (STF, 1ª Turma, HC 162.548, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/06/2020, DJe. 03/07/2020; e STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2018, DJe. 24/08/2018). Veda-se, todavia, por força do

Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF/88), a utilização de "inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ).

Postas estas premissas, ao analisar a Folha de Antecedentes Criminais (fls. 143/144) / Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 145) da parte ré, não se constata nenhuma condenação definitiva por infração praticada antes desta em julgamento. Assim, os antecedentes devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

iii) Na análise da conduta social, consoante a já clássica lição de Bittencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 791), deve-se examinar "o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc." Assim, não se pode confundir os antecedentes sociais da parte ré com os seus antecedentes criminais, de modo que se acabe valorando esses últimos nesta sede (STJ, 5ª Turma, HC 475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/12/2018, DJe. 19/12/2018; e STJ, 6ª Turma, REsp 1.760.972/MG, Rel. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/2018, DJe. 04/12/2018)

Nada há nos autos que desabone a conduta social da parte ré. Assim, sua conduta social deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

iv) Na análise da personalidade do agente, "entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo" (idem, p. 790), deve-se examinar a sua índole e caráter. Este exame deve-se pautar em elementos concretos, sendo insuficiente, para fins de justificação de eventual valoração negativa, a simples menção a uma "personalidade criminosa" (STJ, 6ª Turma, HC 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015, DJe. 11/12/2015)

Não há nos autos elementos concretos que permitam aferir conclusivamente a personalidade da parte ré. Assim, sua personalidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

v) Na análise dos motivos do crime, entendidos como "a fonte propulsora da vontade criminosa" (idem, p. 791), deve-se examinar a natureza e a qualidade dos motivos, ou, na lição de Hungria, citada por Bittencourt (idem, ibidem), se são morais/imorais ou sociais/antissociais.

Os motivos que levaram a parte ré a cometer o delito não fogem daquilo que é comum nos crimes deste jaez. Assim, os motivos devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

vi) Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt (idem, ibidem), as circunstâncias "defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objetos, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes", devendo-se cuidar que "determinadas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime ou, de alguma forma, são valoradas em outros dispositivos, ou até mesmo como elementares do crime", hipóteses em que deverão ser examinadas em outro momento. As circunstâncias em que se deu o crime já estão abrangidas pelo tipo penal (bem como pelas circunstâncias legais a serem avaliadas adiante). Assim, as circunstâncias do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

vii) Na análise das consequências do crime, deve-se ter em vista que essas não se confundem com o resultado natural ou jurídico do crime. Mais uma vez, na lição de Bittencourt (idem, p. 792), cabe "analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime." Não se constata que o crime tenha gerado danosidade que já não esteja abrangida pelo tipo, nem há notícia de alarma social. Assim, as consequências do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

viii) Na análise do comportamento da vítima, deve-se examinar se a vítima contribuiu, de alguma maneira, para a produção do resultado.

O crime em questão é classificado doutrinariamente como delito vago, isto é, conquanto o Estado seja considerado uma vítima indireta, não há nenhuma vítima direta definida, razão pela qual não se cogita do comportamento da vítima para a produção do resultado delitivo.

Para a valoração das circunstâncias judiciais negativas, utilizo a fração de 1/8, filiando-me ao recente precedente do STJ:

"4. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

5. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.

(AgRg nos EDcl no Resp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)"

Havendo uma circunstância judicial negativa, qual seja a culpabilidade, a pena-base fica fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

Na segunda fase da dosimetria, tem-se que:

i) Não incidem quaisquer circunstâncias agravantes nem atenuantes, tendo a parte denunciada se retratado em juízo. Inaplicável, pois, a confissão.

Na terceira fase da dosimetria, tem-se que:

i) Não incidem quaisquer causas de aumento da pena.

Nada obstante a diversidade e quantidade de drogas, entendo possível a aplicação do redutor penal, à razão de 1/3, sendo a ré primária, e possuindo bons antecedentes, o que enseja a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa

A quantidade e diversidade de drogas já foi aferida na primeira fase, não sendo possível considera-la, também, na terceira etapa. Neste sentido:

APELAÇÃO - Tráfico ilícito de drogas privilegiado - Art. 33, caput, c.c. § 4º, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (i) Pleito da d. defesa do acusado no sentido de aguardar o deslinde do recurso em liberdade - Prejudicialidade - (ii) Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais civis - Credibilidade - Precedentes - Acusado que trazia com ele e guardava a quantia líquida de 15,2g de "cocaína", 15,1g de "crack" e 70,1g de "maconha" - Destinação mercantilista dos entorpecentes apreendidos evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Correto o aumento perpetrado na primeira fase da dosimetria penal, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos - Aplicação da máxima fração de redução de penas prevista no § 4º do artigo 33 da mencionada lei especial - Impossibilidade - Redutor máximo que não se aplica a espécie, em razão da natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos ("cocaína", "crack" e "maconha") - Regime prisional semiaberto - Adequado à espécie - Diante da aplicação do redutor e, em razão da natureza e variedade das drogas apreendidas, possível a fixação do regime intermediário - Precedentes do STJ no sentido de que a quantidade, diversidade e/ou a natureza dos entorpecentes é fundamentação idônea para a fixação do regime e vedação da substituição por restritivas de direito - Gratuidade da Justiça - Necessidade - Deve-se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural - APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP; Apelação Criminal 1501862-38.2021.8.26.0537; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 27/09/2022).

AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protraí-se no tempo, o que não

é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. No caso, após prévias informações, os policiais, ao chegarem em frente à residência, visualizaram o paciente deitado no sofá ao lado de certa quantidade de cocaína e, embora o paciente tenha dito que não abriu a porta, afirmou em audiência de custódia que os policiais se identificaram, não arrobaram nada e que teve a intenção de abrir a porta, sendo apreendido 1.023,5g de maconha, além de 0,1g de cocaína. Outrossim, conforme consignado na sentença, o paciente "não compareceu à audiência instrutória a fim de elucidar os fatos". 3. A expressiva quantidade de droga justifica o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. 4. No recente julgamento do HC n. 725.534/SP, a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que as circunstâncias fáticas do caso, sobretudo a natureza, a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas, se extrapolarem os limites da razoabilidade, podem justificar a aplicação do redutor do tráfico em índice diverso do máximo. 5. A quantidade de droga arrecadada (1023,5g de maconha, além de 0,1g de cocaína) - que não se revela ínfima, tampouco pode ser considerada vultuosa -, aliada à apreensão de apenas duas variedades de entorpecentes, não justifica a incidência do redutor em seu máximo, afigurando-se mais razoável a aplicação da fração de 1/2, utilizada pela sentença e confirmada pelo Tribunal de origem. 6. Agravo regimental da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina improvido. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina provido, para restabelecer o acórdão de origem. (AgRg no AgRg no HC n. 717.663/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Valor do Dia-Multa

Fixo o valor da dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), uma vez que não há nos autos dados suficientes à análise exauriente da situação econômica da parte ré (art. 60, caput, do CP).

Detração

Deixo de efetuar a detração (art. 42 do CP), como manda o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes informações suficientes sobre imposição e cumprimento de penas privativas de liberdade por outros crimes (art. 111 da LEP).

Regime Inicial de Cumprimento

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena é feita a partir da aferição de quatro critérios: tipo de pena prevista para o tipo legal (reclusão ou detenção), quantidade de pena aplicada, reincidência e circunstâncias judiciais (art. 33, §§2º e 3º, do CPP), sendo certo que a imposição de regime mais severo do que o permitido pela pena aplicada exige motivação idônea (Súmula 719-STF: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea"), exigência essa não satisfeita pela mera menção à gravidade em abstrato do crime (Súmula 718-STF: "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada").

Portanto, entende-se como correto o estabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos

Dispõe o art. 44 do CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1o (VETADO)

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

A pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos, pois estão presentes os requisitos legais que a autorizam: pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos (art. 44, I, primeira parte do CP); crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, segunda parte do CP); réus não reincidentes em crime doloso (art. 44, II do CP); a culpabilidade, os antecedentes, a conduta